

通过事前还是事后约定知识产权惩罚性赔偿机制，都可以在商业活动中根据当事人意思自治原则为利用知识产权开展相关经营活动的商事主体赋以更高的侵权或违约成本，有效发挥惩罚性赔偿对于知识产权侵权的遏止作用。

(三)降低司法成本的优选手段

在知识产权惩罚性赔偿案件中，原告为达到惩罚性赔偿相关要件的证明目的，通常需要付出较高的举证成本，特别是为计算惩罚性赔偿的基数需要进行大量的举证工作，举证的时间成本和经济成本非常可观。对法院而言，审查相应证据判断是否应当适用惩罚性赔偿及其基数、倍数的计算方式也会占用大量的司法资源。在约定惩罚性赔偿的场合，当事人就基数和倍数的适用达成合意，可以很大程度上减少司法案件中当事人的举证成本，也为法院审查原告方的惩罚性赔偿主张提供了重要参考，有效降低了整体司法成本。

二、约定惩罚性赔偿适用条件审查

(一)受保护的知识产权指向明确

在约定惩罚性赔偿条款中，受保护客体的明确是首要问题，也是影响约定条款效力的重要因素。一般而言，约定的知识产权可分为以下几类：一是在订立约定条款时效力稳定的权利。例如，权利人已经持有的稳定的注册商标、享有的作品著作权权利等。二是在订立约定条款时可预见的权利。例如，正在申请流程中的商标、尚未完稿的作品等。三是在一定范围内可确定的权利。例如，视频平台在未来数年内采购的影视剧版权、某公司纳入保密范围在未来可能产生的商业秘密等。通过约定惩罚性赔偿条款保护的知识产权的指向应当明确，至少达到可合理预见的标准，相关条款方才存在成立的空间。

(二)约定了可计算的基数

基数的确定是惩罚性赔偿适用的核心，也是司法实践中限制绝大多数侵权案件适用惩罚性赔偿的因素。在约定惩罚性赔偿条款中约定基数是惩罚性赔偿得以适用的前提。基数的约定可分为几类：一是约定固定值。该

类约定多见于 知识产权价值难以量化，或是侵权人规模较小的情形，通过约定惩罚性赔偿基数固定值进而便于直接适用惩罚性赔偿。二是约定明确的计算方式。应当指出

的是，对于惩罚性赔偿计算方式无需明确基数计算的各项数值，而是对计算方式中涉及的各项要素进行指向性的约定达到明确的程度即可。对于尚未约定的部分要素，若双方无法协商一致，在适用合同漏洞填补规则可予以明确的情况下，也应当视为双方就基数计算有效达成合意。

（三）明确约定倍数

惩罚性赔偿倍数的约定若在法定惩罚性赔偿倍数范围内，其约定的效力一般不会存在争议。当约定倍数超过法定惩罚性赔偿倍数时，实务中存在不同的观点。《北京市高级人民法院关于侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿审理指南》第3.21条中规定，当事人约定惩罚性赔偿的倍数不在法定范围内，并请求适用约定的惩罚性赔偿倍数的，一般予以支持，但对对方当事人提出异议并提供有效证据证明该约定明显不合理的除外。而也有观点认为，惩罚性赔偿并不等同于补偿性赔偿，其具有强制性色彩，因此法律规定的倍数限制应当为效力强制性规定，不宜突破。从《中华人民共和国民法典》第一百五十三条、《中华人民共和国商标法》第六十三条、《中华人民共和国著作权法》第五十四条等法条角度出发，法律对于侵权惩罚性赔偿倍数是基于侵权责任的规定，法条本身并未针对当事人实施的民事法律行为效力进行规制，以认定为非效力强制性为宜。当事人间通过合同约定惩罚性赔偿的倍数在性质上可以认为是惩罚性违约金，该约定的效力本身不应受前述侵权责任相关法条影响，应认定有效为原则。至于原告在维权时参考该约定主张侵权责任，或直接主张违约责任，以及主张的倍数是否合理，是否应当调整，应当根据实际情况参考合同违约金调整的规范具体分析。

三、约定惩罚性赔偿基数和倍数的审查

（一）是否符合适用惩罚性赔偿的法定条件

无论当事人对惩罚性赔偿条款进行了何种约定，其实质均为对损害赔偿的金额达成合意，对于是否能够在侵权案件中适用惩罚性赔偿，人民法院仍需结合案情对惩罚性赔偿的适用条件进行审查。即使当事人约定了适

用惩罚性赔偿 具体情形，仅可作为侵权案件中审查侵权故意和情节严重的参考。对于侵权故

意情形的约定一般不会产生争议，在侵权认定中也可直接援引。当双方针对情节严重的具体表现情形进行约定时，除非有相反证据证明侵权情节未达到严重程度，原则上法院也应当将约定情形采纳作为侵权情节严重的考量因素。

(二)基数计算方式是否合理

在审查基数计算方式合理性时，应当主要考量以下几个因素：(1)是否符合市场经营的一般规律。基数约定的金额或计算方式应当符合行业惯例或市场经营主体经营活动的基本逻辑。本案中双方约定以酒店月营业收入的比例计算商标许可使用费，符合酒店行业经营惯例。(2)是否考量了实际经营各项因素。基数计算还应当考虑市场主体实际开展经营过程中可能影响基数计算的因素。本案中酒店的月营业收入无法准确查明的情况下，还应当充分考虑某些不可抗力因素对酒店经营期间所造成的影响。(3)是否需要由法院酌定的因素。在计算方式的各项数额无法精确查明的情况下，法院可对相关要素的具体数值进行酌定。本案中法院就结合在案证据酌情确定了入住率、客单价等数据，根据合同约定积极确定惩罚性赔偿基数。

(三)倍数是否与侵权情节相适应

即使当事人通过合同对惩罚性违约金的基数和倍数进行了较为明确的约定，但在原告发起的侵权诉讼中，惩罚性违约金并不能转化为惩罚性赔偿直接适用，特别在倍数确定时，仍应结合案情进行审查。在法定范围内的倍数约定，侵权案件应以支持适用为原则。特别应当注意的是，除《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》等法条明确规定外，在上海市浦东新区适用的《上海市浦东新区建立高水平知识产权保护制度若干规定》规定了五倍以上十倍以下的惩罚性赔偿倍数。对于法定范围以外的倍数约定，原告需要在侵权案件中进一步举证侵权行为特别严重的情节。在法定范围内的倍数则还应综合考虑侵权行为持续时间、规模、获利等因素，主要为避免合同惩罚性赔偿约定条款泛定格化的情况，更好地发挥惩罚性赔偿的遏止知识产权侵权的作用。

驰名商标跨类保护范围的合理划定

—— 某信息公司诉某油条公司等侵害商标权及不正当竞争案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省高级人民法院(2023)粤民终1063号民事裁定书

2. 案由：侵害商标权及不正当竞争纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 某信息公司

被告(被上诉人): 某油条公司、赵某、某食品公司

【基本案情】

某信息公司系第1××3号**今日头条**、第1××8号、第2××8号**紧**、第2××9号**今日头条**四个注册商标专用权人，上述商标分别使用在第9类“计算机软件”等及第38类“通过计算机软件提供信息传送服务”等商品、服务上。某信息公司诉称，其持续对上述商标进行宣传，在计算机程序等商品服务的相关公众中已享有较高的知名度与市场影响力，构成驰名商标。某油条公司等开设早餐店售卖油条、豆浆等食品，在餐馆招牌、菜单、食品包装、店铺装潢、员工服装、微信公众号、网站、招商加盟广告及展览会等多处大量使用**今日油条**标识，使用引人误认的广告语、宣传材料、海报，构成侵害其驰名商标的行为并构成不正当竞争。请求法院判令某油条公司等停止侵权、消除影响并赔偿经济损失200万元。

【案件焦点】

1. 某油条公司等的被诉行为是否构成普通商标侵权；2. 如果某信息公司四个注册商标中的部分商标可以认定为驰名商标，某油条公司等的被诉行为是否构成对驰名商标的侵权；3. 某油条公司等的被诉行为是否构成不正当竞争；4. 如果构成侵权，某油条公司等应当承担的法律责任。

【法院裁判要旨】

广州知识产权法院经审理认为：某油条公司等人在制售油条等食品过程中，以及在宣传“今日油条”加盟项目过程中使用瑶、**今日油条**标识，属于商业性、识别性使用行为，可以产生识别商品或服务来源的作用，属于商标法规定的商标性使用行为。涉案四个注册商标核定使用的商品或服务分别属于《类似商品和服务区分表》第9类和第38类，与被诉标识使用的第30类、第43类商品服务类别既不相同也不类似。被诉标识与涉案注册商标在文字、含义、颜色等构成要素上不构成相同或相似，相关公众施以一般注意力易于区分，现有证据未能证实某油条公司等具有混淆故意或已造成公众实际混淆，故某油条公司等不构成普通商标侵权。

涉案注册商标使用的文字“头条”“今日头条”属于常用词汇，使用在新闻资讯领域固有显著性较弱，被诉侵权标识与涉案注册商标分别使用在完全不同的市场，某信息公司在餐饮领域不具有现实利益，双方在该市场上没有直接或间接的竞争关系，某油条公司等未对驰名商标造成弱化、贬损或丑化，亦未存在不正当利用驰名商标市场声誉的情形。故即使涉案注册商标中的部分商标可以认定为驰名商标，某油条公司等亦不构成对驰名商标的侵害，本案中对涉案四个注册商标是否驰名没有审查的必要性。

某油条公司使用的企业字号“今日油条”与“今日头条”区别明显，其在微信公众号、网站等使用的被诉侵权标识与“今日头条”手机APP的运行界面不构成相同或近似，二者的广告语及海报存在差异，故某油条公司等行为亦未构成不正当竞争。

综上，某信息公司诉请某油条公司等停止侵权、赔礼道歉并赔偿损失于法无据。

广州知识产权法院依据《中华人民共和国商标法》第十三条、第四十八条、第五十六条、第五十七条、第五十八条，《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第六条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条、第十一条、第十二条，《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第九条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》第十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条的规定，经法院审判委员会讨论决定，判决如下：

驳回某信息公司的诉讼请求。

某信息公司不服一审判决，提起上诉。后其申请撤回上诉，广东省高级人民法院作出民事裁定书，准许其撤回上诉。

【法官后语】

本案涉及“今日头条”等知名商标，自立案起即受到社会高度关注，并引起业界对合理划定驰名商标跨类保护范围问题的广泛讨论。本案从混淆及淡化两个维度对被诉行为是否构成商标侵权进行了详细论证，进一步明确了驰名商标淡化构成的认定标准，对“显著性”判断、“相当程度的联系”“相关公众”“误导公众”内涵以及淡化行为具体类型等重点问题的考量因素及定性进行了详细阐述，为互联网经济环境下驰名商标保护提供了重要的分析样本。

一、驰名商标保护的基本原则

（一）宽严适度的高质量保护原则

驰名商标系通过市场主体长期使用、宣传，以其优质产品或服务为基石建立起良好商业信誉的载体，承载巨大的商业价值，并可转化为市场竞争优势。提供高质量的驰名商标保护，对培育高质量中国品牌、优化营商环境、引领经济高质量发展具有重要意义。知识产权保护由“强化保护

”转化为“全面 加强保护”,既包括对拓展保护链条、保护手段及参与主体覆盖面的要求,亦

